

1506932-33.2021.8.26.0344  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari  
Comarca: Marília  
Foro: Foro de Marília  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 30/05/2022  
... autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, acondicionados individualmente e prontos para a venda a terceiros (fl. 35); b) as somas em dinheiro, em notas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Marília  
Foro de Marília  
2ª Vara Criminal  
Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata  
CEP: 17519-902 - Marilia - SP  
Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1506932-33.2021.8.26.0344 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1506932-33.2021.8.26.0344  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JONATHAN HENRIQUE MATTOS DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE MATTOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 5 de agosto de 2021, por volta das 7 horas, na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, nº 421, fundos, nesta cidade e Comarca:

(i) guardava, para fins de tráfico, 32 (trinta e dois) microtubos de crack, com peso líquido de 3,99 g (três gramas e noventa e nove centigramas), e 105 (cento e cinco) microtubos de cocaína, com peso líquido de 27,76 g (vinte e sete gramas e setenta e seis centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 39/41 e 98/102, além da quantia de R\$ 412,00 (quatrocentos e doze reais).

(ii) o denunciado associou-se com o adolescente D. G. M. dos S., de 17 anos de idade, para fins de praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).

Foi preso em flagrante delito e houve a conversão da prisão flagrancial em preventiva (fls. 66/76). O réu foi notificado (fl. 124) e ofertou defesa prévia (fls. 158/159). A denúncia foi recebida em 8/3/2022 (fls. 161/163) e o réu foi citado (fl. 191). Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 5/4/2022 (fls. 193/194), foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. Em continuação, no dia 24/5/2022, foi ouvida uma testemunha comum e o acusado foi interrogado (fls. 212/218).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, pois restou comprovado que estava praticando o tráfico de drogas de forma associada com o menor. Quanto à dosimetria, pugnou pela fixação da pena acima do mínimo legal na primeira fase em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase é necessário novo aumento em função da reincidência e na terceira fase incabível o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 213/214).

A Defensoria Pública, em alegações finais ofertadas às fls. 215/218, argumentou que a prova não é suficiente para condenação porque o irmão do acusado assumiu a propriedade da droga e não foi constatada nenhuma situação concreta de traficância ou investigação prévia apontando o acusado, recaindo sobre ele apenas indícios.

Além disso, ponderou que não há prova do ânimo associativo e duradouro para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, bem como deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, pois a conduta do adolescente não foi pormenorizada na denúncia e a prova não revela que o sentenciado se beneficiava de ações praticadas pelo menor. Pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII do CPP, aplicação de pena base no mínimo legal, com afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas e fixação de regime prisional abrandado, além de observação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante de fls. 7/8, boletim de ocorrência de fls. 29/32, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33/34, pelas fotografias de fls. 35/37, pelos laudos de constatação provisória de fls. 39/41 e laudo químico toxicológico de fls. 98/102, este atestando a natureza das substâncias apreendidas (Cocaína), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 335/367) e prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Samara Maroni Vasconcelos, policial civil, declarou ter sido realizada na DISE uma investigação que apontava que o réu estava traficando drogas no local dos fatos, na companhia de um adolescente conhecido como "Neguinho". O réu já era conhecido dos policiais por ter sido preso, no mesmo local, dois anos antes, na posse de entorpecentes. Após o deferimento de mandado de busca e apreensão, na data dos fatos realizaram a diligência. O réu foi localizado em um quarto, dormindo, e no bolso da sua blusa foi localizada uma "muca" contendo 52 "pinos" de cocaína

maiores e 53 "pinos" menores. No quarto em que ele estava também havia R\$ 342,00. No outro quarto da casa encontraram o adolescente D.G.M.S., vulgo "Neginho", irmão do réu. Em revista pessoal nada foi encontrado com ele. Contudo, no guarda-roupas, havia uma blusa pertencente ao adolescente, contendo 32 "pinos" amarelos de crack. Também foi localizada a quantia de R\$ 70,00. O réu negou ser proprietário do entorpecente, inclusive daquele encontrado em sua blusa. O adolescente D.G.M.S. assumiu a propriedade todo o entorpecente, indicando que havia 180 porções. Contudo, na verdade, foram encontradas apenas 132 porções.

A testemunha Edenyr Alfredo Bedusqui, policial civil, declarou que o réu já era conhecido pela prática do tráfico de drogas, pois já havia sido preso em sua casa com grande quantidade de entorpecentes. Receberam informações de que, após ter sido posto em liberdade, voltou a comercializar entorpecentes. Após ser deferido mandado de busca e apreensão na residência do réu, foram no local pela manhã. Encontraram o réu deitado em sua cama. No bolso da blusa que ele usava, havia duas "mucas", uma com 52 "pinos" de cocaína grandes, na cor amarela, e outra com 53 "pinos" de cocaína menores, também da cor amarela. O réu também tinha a quantia de R\$ 343,00. O irmão do réu foi localizado em um quarto nos fundos da casa. Na blusa dele, que estava no armário, havia mais uma "muca" com 32 "pinos" de crack. Em uma cômoda foi encontrado R\$ 70,00.

O réu Jonathan Henrique Mattos dos Santos, interrogado, declarou que no dia anterior aos fatos foi buscar uma pizza e vestiu a blusa do seu irmão. Voltou e dormiu com a blusa. No dia seguinte foi acordado pelos policiais. A droga encontrada na blusa pertencia a seu irmão, que estava passando um período em sua casa.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A negativa ofertada pelo acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, não sendo crível que vestiu uma blusa do irmão contendo o volume fotografado à fl. 35 sem que notasse ou se incomodasse, inclusive dormindo com a vestimenta.

Em contrapartida, os relatos dos policiais civis foram coesos e uníssonos no sentido de que houve uma investigação prévia a partir de informações, apontando que o sentenciado traficava naquele local. Também ofertaram detalhes da diligência de busca e apreensão, na qual encontraram quantidade considerável de droga na posse do acusado e do adolescente.

Portanto, a partir da investigação prévia, a busca e apreensão resultou positiva, não sendo imprescindível para o deslinde do feito ou para a condenação que seja o réu flagrado vendendo o entorpecente para terceiros. Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, acondicionados individualmente e prontos para a venda a terceiros (fl. 35); b) as somas em dinheiro, em notas diversificadas, localizada na residência do réu sem comprovação de origem lícita; c) a apreensão de entorpecentes na vestimenta do adolescente, com embalagens semelhantes àsquelas encontradas na posse do acusado; d) as informações prévias de que o réu estava traficando drogas..

Como se vê, a prova oral está em consonância com a prova pericial que instrui os autos, inexistindo qualquer discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do comércio de drogas, bem como a autoria do

crime.

Tratando-se, especificamente, do delito de associação para o tráfico, com razão a Defensoria Pública. Embora haja indícios de unidade de propósitos entre o acusado e o adolescente, não há provas efetivas da ocorrência do crime e, por esta razão, a absolvição do réu é medida que se impõe.

O liame subjetivo característico da associação não foi demonstrado nos autos. Não se sabe se a traficância se dava de forma habitual e permanente ou se foi uma situação isolada e não há nada a respeito de hierarquia ou divisão de tarefas bem definidas entre eles.

Nesse sentido o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: "Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006." (STJ - AgRg no HC 539.907/RJ T5 - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. em 17.12.2019 DJe em 19.12.2019).

No que concerne à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Drogas, restou comprovado que o réu envolveu o adolescente D. G. M. dos S. (17 anos de idade - fl. 15), seu irmão, no delito apurado nos autos. Afinal, quando da busca e apreensão, também foi localizada em vestimenta pertencente ao adolescente algumas porções de droga e dinheiro no cômodo no qual estava, havendo claro alinhamento subjetivo com os fatos descritos na denúncia.

A par disso, afasto a tese defensiva de que a denúncia não descreveu de forma pormenorizada a ação do adolescente. A peça acusatória transcreve que as investigações prévias apontavam que o réu exercia o tráfico na companhia de um adolescente de alcunha "Neguinho". Além disso, faz menção de que durante a diligência de busca e apreensão, os policiais encontraram guardados dentro de uma blusa pertencente ao menor mais porções de entorpecentes, exaurindo qualquer dúvida do seu envolvimento com o comércio ilícito praticado pelo sentenciado.

Portanto, denota-se pelas provas coligidas que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, perfazendo 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Apesar da quantidade apreendida, a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base, anotando-se que o único registro constante nas fls. 49/51 será sopesado na próxima fase da dosimetria.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante consistente na reincidência do acusado (processo nº 1502457-05.2019.8.26.0344 - fls. 49/51 - trânsito em julgado em 5/8/2020), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu.

A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no dispositivo legal mencionado acima, haja vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o réu seja primário. E por ser a reincidência apenas um dos requisitos que impede a incidência do benefício penal, não sendo elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em bis in idem.

Desta forma, torno definitiva a pena do acusado em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu JONATHAN HENRIQUE MATTOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu é reincidente e dada a gravidade do delito, que é equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não terem atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Registro, ainda, que apenas o Juízo das Execuções possui o quadro completo das condenações do réu, de seu comportamento carcerário e de seu merecimento e, portanto, pode realizar a detração com maior rigor e acuidade.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada (fls. 66/76) em virtude da prisão em flagrante com considerável quantidade de entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que ainda persistem os requisitos para manutenção da custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Além disso, há registro de duas condenações por tráfico, restando uma delas pendente de recurso (fls. 49/51), denotando reiteração delitiva que deve ser coibida para garantia da ordem pública. Destarte, mantenho a prisão preventiva do referido réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a

fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o artigo 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do bem consistente no numerário objeto dos depósitos judiciais de fls. 103/104.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA